

SUHAIDA BINTI MAHIYUDIN
lwn.
DANIEL JOE HENRY BIN ABDULLAH

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Ahli Panel)

09 Januari 2024 / 27 Jamadilakhir 1445H

Permohonan Semakan No. 2311-A0010-003-0119

(Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003)

Pegum Syarie Pemohon: Tuan Muhammad Zahir bin Ismail (Tetuan Wali Azri & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

- 1- Kes ini ialah suatu permohonan untuk menyemak keputusan tindakan pengkomitan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 12/10/2022.
- 2- Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan perintah bahawa Pemohon diperintahkan dikomitkan ke penjara selama tujuh (7) hari dan Mahkamah

menanggihkan pengkomitan penjara ke atas Pemohon. Pemohon diperintahkan untuk mematuhi perenggan 3 dan 5 Perintah Interim Hadhanah dalam tempoh tiga bulan dan sekiranya pematuhan perintah tersebut dilakukan, perintah pemenjaraan dibatalkan.

LATAR BELAKANG KES

3- Pemohon dan Responden telah bernikah pada 24/12/2006 dan bercerai pada 15/10/2020. Mereka dikurniakan dengan tiga (3) orang cahaya mata iaitu:

- 2.1 Danish Danial bin Joe Henry (NO.K/P: 080108-87-0095) – 16 Tahun.
- 2.2 Dayana Batrisya binti Joe Henry (NO.KIP: 130826-10-0960) – 11 Tahun.
- 2.3 Diana Elysha Butiza binti Joe Henry (NO.K/P: 150514-87-0024) – 9 Tahun.

4- Pada 25/07/2019, Pemohon telah memfailkan tuntutan hak jagaan anak di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam melalui Saman No. 10207-028-0298-2019. Pemohon telah selesai memberi Keterangan dan YA Hakim Bicara telah menemu bual anak pertama dan anak kedua. Seterusnya pada 06/03/2024, Mahkamah menetapkan pihak Responden selaku Defendan memberikan keterangan.

5- Pada 18/05/2022, Responden telah memfailkan Permohonan Interim Hak Jagaan Anak melalui kes Permohonan No. 10207-038-0229-2022. Seterusnya, pada 11/10/2022, YA Hakim Bicara telah mengeluarkan perintah bagi hak jagaan sementara seperti berikut:

1. *Mahkamah meluluskan permohonan pihak Pemohon berdasarkan Seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;*
2. *Mahkamah memerintahkan hak jagaan tiga (3) orang anak yang bernama Danish Danial Joe Henry (No. Mykid: 080108-87-0095), Dayana Batrisya Joe Henry (No. Mykid : 130826-10-09 60) dan Diana Elysha Butiza Joe Henry (No. Mykid : 150614-87-0024) diserahkan kepada Responden (ibu) sehingga ada Mahkamah mengeluarkan perintah berkenaan penjagaan anak atau sehingga ada perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.*
3. *Mahkamah memerintahkan hak bersama dan bermalam bagi anak-anak tersebut diberikan kepada Pemohon (ayah) setiap bulan pada minggu pertama dan minggu ketiga iaitu pada hari Jumaat diambil selepas pukul 6 petang dan dipulangkan pada hari Ahad sebelum pukul 6 petang.*
4. *Mahkamah memerintahkan hak lawatan anak-anak tersebut termasuk di sekolah pada bila-bila masa yang sesuai dan munasabah dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Responden.*
5. *Mahkamah memerintahkan lokasi pengambilan dan penyerahan anak-anak tersebut hendaklah dibuat di mana anak-anak tersebut tinggal. Sekiranya berlaku apa-apa perubahan alamat tempat tinggal anak-anak tersebut, Responden perlu memaklumkan kepada Permohon.*
6. *Mahkamah memerintahkan Pemohon diberikan akses untuk berkomunikasi bersama anak-anak tersebut melalui apa juga media perhubungan ke nombor telefon anak-anak tersebut pada bila-bila masa yang sesuai dan munasabah.*
7. *Mahkamah memerintahkan bahawa Pemohon dan Responden dan /atau ejennya, ahli keluarga atau mana-mana wakil dari kedua-dua pihak*

adalah ditegah dan dilarang daripada membawa anak-anak tersebut keluar dari Malaysia kecuali dengan kebenaran bertulis dan pengesahan secara lisan daripada Pemohon dan/atau Responden...

6- Pemohon dan Responden telah cuba melaksanakan Perintah Interim tersebut sebanyak dua kali iaitu pada 21/10/2022 dan 04/11/2022. Walau bagaimanapun atas sebab-sebab tertentu perintah tersebut telah gagal dilaksanakan.

7- Pada 09/12/2022, Responden telah memfailkan satu Permohonan Kebenaran Pelaksanaan Komital terhadap Pemohon berdasarkan Seksyen 151 dan seksyen 229 (1) dan (3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Pemohon kemudiannya melalui Peguam Syarie telah menjawab Notis Tunjuk Sebab tersebut melalui Afidavit Jawapan Responden bertarikh 14/04/2023. Seterusnya, Responden telah membalas Afidavit Jawapan Pemohon melalui Afidavit Balasan pada 30/05/2023. Responden telah memfailkan hujah bertulis pada 07/07/2023, manakala, Pemohon melalui Peguam Syarie saya telah memfailkan hujah pada 14/07/2023. YA Hakim Bicara telah memberikan keputusan pada 12/10/2023.

ALASAN PERMOHONAN

8- Pemohon memfailkan permohonan ini berdasarkan alasan seperti berikut:

8.1 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang undang serta Hukum Syarak apabila tidak memutuskan kes tanpa mengambil kira isu dan fakta dalam Notis Tunjuk Sebab;

- 8.2 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang serta Hukum Syarak apabila tidak menjalankan siasatan terhadap keadaan sebenar yang berlaku berkaitan tempat perjumpaan dan cara perjumpaan Pemohon, Responden dan anak-anak tersebut;
- 8.3 YA Hakim telah khilaf apabila gagal menjalankan prosedur perbicaraan dan / atau penyiasatan terhadap Pemohon dan Responden dengan sewajarnya dan munasabah dan / atau tidak memanggil langsung Pemohon dan Responden untuk sesi siasatan / perbicaraan dan / atau untuk justifikasi keterangan / pliding pihak-pihak;
- 8.4 YA Hakim telah khilaf apabila gagal menjalankan prosedur perbicaraan dan / atau penyiasatan terhadap anak-anak tersebut sebagai subjek pertikaian kes komital dengan sewajarnya dan munasabah; dan
- 8.5 YA Hakim telah khilaf apabila memutuskan satu perintah yang cacat dan tidak jelas pelaksanaannya yang boleh menganiaya Pemohon.

ISU

9- Kami akan mengulas permohonan ini berdasarkan dua isu yang diketengahkan iaitu:

- 9.1 Sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf apabila gagal mempertimbangkan tunjuk sebab yang telah diberikan oleh Pemohon.

9.2 Sama ada perintah yang dikeluarkan cacat dan tidak jelas pelaksanaannya.

ANALISIS DAN DAPATAN MAHKAMAH

10- Permohonan ini dibuat dengan merujuk Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 berkaitan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah.

11- Kami maklum bahawa tujuan kuasa semakan ini telah dirungkaikan dalam beberapa kes tersohor antaranya kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2)**, kes **Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012**, kes **Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011**, Kes **Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012**.

12- Seterusnya kami juga merujuk **Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah)** berkaitan panduan kriteria- kriteria kes yang boleh dipohon melalui semakan.

Isu Pertama: Sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf apabila gagal mempertimbangkan tunjuk sebab yang telah diberikan oleh Pemohon.

13- Bagi maksud semakan ini, kami telah memanggil rekod prosiding kes Permohonan No. 2212-H0610-415-0123. Hasil semakan terhadap rekod tersebut, kami mendapati YA Hakim Bicara telah membuat keputusan berdasarkan affidavit jawapan, affidavit balasan dan hujah pihak-pihak tanpa menjalankan siasatan lanjut terhadap Pemohon dan anak-anak yang menjadi subjek pertikaian dalam kes pelaksanaan perintah tersebut.

14- Pemohon melalui Affidavit Jawapan telah mengemukakan beberapa tunjuk sebab khususnya berkaitan kehendak anak-anak yang tidak mahu bermalam bersama Responden kerana “belum biasa”. Walau bagaimanapun kami mendapati tiada ulasan lanjut YA Hakim Bicara berkaitan perkara tersebut. YA Hakim Bicara telah menyimpulkan bahawa punca pelanggaran dan penafian perintah Mahkamah adalah disebabkan Pemohon telah mengubah tempat pengambilan anak-anak daripada tempat tinggal di Taman Bangi Avenue, Selangor ke lokasi Starbucks, yang juga terletak di Bangi Avenue, Selangor. Pada hemat kami walaupun terdapat perubahan pada tempat pengambilan tersebut, namun ia masih tidak menjejaskan pelaksanaan perintah kerana tempat tersebut berada dalam kawasan tempat tinggal yang sama dan ia juga sebelum dilaksanakan telah dipersetujui oleh Responden.

15- Hasil penelitian secara menyeluruh kami terhadap rekod prosiding kes, kami berpendapat tindakan YA Hakim Bicara yang bergantung semata-mata dengan keterangan secara bertulis tanpa ada siasatan lanjut berkaitan pembelaan yang diberikan oleh Pemohon menyebabkan YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam mengenal pasti punca utama mengapa perintah interim tersebut gagal dilaksanakan. Kami berpendapat kehendak anak-anak dan latar belakang tempat tinggal sebelum dan semasa Pemohon dan anak-anak yang berjauhan dengan Responden di UK dan

Sabah juga seharusnya dipertimbangkan memandangkan perintah interim tersebut baru dikeluarkan untuk dilaksanakan.

16- Kami berpendapat sebab-sebab yang diberikan oleh Responden seharusnya dihalusi dengan lebih mendalam oleh YA Hakim Bicara memandangkan dalam kes hadhanah atau yang melibatkan hadhanah, pertimbangan utama Mahkamah ialah berkaitan faktor kebajikan kanak-kanak selaras dengan konsep **حق المحضون** sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 8 yang antara lain menyatakan:

إن لكل من الحاضنة والمحضون حقا في الحضانة ، إلا أن حق المحضون أقوى من حق الحاضنة

“Sesungguhnya setiap yang menjaga dan yang dijaga (anak) mempunyai hak di dalam hal pemeliharaan tetapi hak yang dijaga (anak) lebih kuat daripada hak yang menjaga.”

17- Dalam kitab ‘*Al-fiqh al-Muqarran lil ahwal syakhsiyyah*’ oleh Badran Abdul Ainami, Juzuk 1, halaman 543 hingga 544 pula menyatakan :

غاية لامر أن حق الصغير أقوى لان مصلحته مقدمة على مصلحه ابويه وانه يجب العمل بما هو انفع
واصلح للصغير في باب الحضانه

“ Tujuan hadhanah adalah ditujukan kepada anak itu dan hak anak adalah lebih utama kerana kebajikan adalah didahulukan dari kebajikan kedua ibubapanya. Mengutamakan kebajikan anak adalah dimestikan kerana dengan itu akan dapat mencapai perkara yang terbaik lagi elok untuk anak itu dalam bab hadhanah.”

18- Jika perlu Mahkamah boleh memanggil anak yang berkaitan untuk mendapatkan keterangan lanjut berkaitan pembelaan yang diberikan oleh Pemohon sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes **Alan Van Niekerk lwn. Yustriati binti Md Hashim, Kes Mal (Rayuan) No. 14000-078-0058-2020 bertarikh 25/01/2022 (Belum dilaporkan).**

19- Kami ingin menegaskan bahawa prosiding komital adalah suatu prosiding yang serius, lebih-lebih lagi melibatkan hukuman pemenjaraan ke atas ibu atau bapa yang mempunyai tanggungjawab terhadap anak-anak. Oleh itu ia seharusnya dikendalikan dengan lebih berhati-hati dan setiap keperluan perundangan mesti dipatuhi. Memandangkan pembelaan Pemohon tidak disiasat secara menyeluruh oleh YA Hakim Bicara maka kami berpendapat peluang yang sewajarnya perlu diberikan bagi memastikan kebenaran apa yang telah dinyatakan.

Isu Kedua: Sama ada perintah yang dikeluarkan cacat dan tidak jelas pelaksanaannya

20- Dalam kes ini kami mendapati YA Hakim Bicara telah menolak tunjuk sebab yang diberikan oleh Pemohon dan memerintahkan Pemohon dikomitkan ke penjara selama tujuh (7) hari. Seterusnya YA Hakim Bicara telah menangguhkan hukuman penjara dan memerintahkan Responden mematuhi perenggan 3 dan 5 Perintah Interim Hadhanah dalam tempoh 3 bulan dan sekiranya pematuhan perintah tersebut dilakukan, Mahkamah akan membatalkan perintah pemenjaraan. Dengan perintah yang diberikan tersebut kes tindakan pengkomitan dianggap selesai dan fail kes ditutup.

21- Kami mendapati YA Hakim Bicara telah menggunakan budi bicara menangguhkan pelaksanaan hukuman setelah mensabitkan bahawa Pemohon bersalah dan dihukum penjara selama 7 hari berdasarkan rujukan terhadap **Arahan Amalan No. 13 Tahun 2004**.

22- Pihak Pemohon pula mempersoalkan sama ada YA Hakim Bicara boleh menangguhkan pelaksanaan perintah dalam keadaan tidak ada permohonan penggantungan dan tidak ada notis rayuan difailkan. Perkara ini tidak selaras dengan prinsip penggantungan pelaksanaan perintah sebagaimana ditegaskan dalam kes **Jaya Harta Realty Sdn Bhd v. Koperasi Kemajuan Pekerja-Pekerja Ladang Bhd [2000] 3 CLJ 361** iaitu:

“The justice of the case on stay is arrived at by striking a judicious and equitable balance between the principle that the successful party in the litigation ought to be allowed to reap the fruits of that litigation and not obtain a mere barren success, and the countervailing principle that should the unsuccessful party in litigation be ultimately successful in his appeal, he ought not be deprived of the fruits of his litigation due to the result of his appeal being rendered nugatory.”

23- Dalam mengulas isu ini, kami berpeluang merujuk kes **Juris Technologies Sdn Bhd & Anor v. Foo Tiang Sin & Ors [2019] 9 CLJ 617** yang menjelaskan berkaitan tindakan pengkomitan berdasarkan Aturan 52 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012.

“[25] When the court finds a person guilty of contempt of court, the court has a discretion to impose the following sentence on the contemnor:

- (i) under O. 52 r. 7(1) RC, the court may suspend the execution of the order of committal:
 - (a) for any period of time; and/or

(b) based on any term or condition
- as may be specified by the court.

When the court suspends the execution of a committal order according to O. 52 r. 7(1) RC, the court may admonish, caution or reprimand the contemnor;

- (ii) the court may discharge a contemnor pursuant to O. 52 r. 8(1) or (2) RC;

24- Kami turut merujuk Kaedah 7, Aturan 52, Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 berkaitan tindakan pengkomitan memandangkan tiada tatacara yang jelas berhubung perkara tersebut diperuntukkan dalam Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah.

Mahkamah yang membuat perintah pengkomitan boleh melalui perintah mengarahkan bahawa pelaksanaan perintah pengkomitan itu hendaklah digantung bagi apa-apa tempoh atau atas apa-apa terma atau syarat sebagaimana yang ia boleh nyatakan

25- Berdasarkan alasan-alasan tersebut kami berpuas hati bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila menggantung pelaksanaan perintah pengkomitan berpandukan rujukan kepada Kaedah 7, Aturan 52 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012. Walau bagaimanapun pada hemat kami tindakan pelepasan orang yang dikomitkan seharusnya dibuat oleh Mahkamah atas permohonan mana-mana orang yang dikomitkan selaras dengan Kaedah 8, Aturan yang sama dan Mahkamah hendaklah menetapkan suatu tarikh yang lain untuk memantau pelaksanaan syarat-syarat penggantungan pelaksanaan perintah sebagaimana yang telah ditetapkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan dan menyemak rekod prosiding kes, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan seperti berikut:

- 1) Permohonan Pemohon DITERIMA.
- 2) Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 12/10/2023 dalam Kes Mal No. 2212-H0610-415-0123 DIBATALKAN.
- 3) Siasatan lanjut perlu dijalankan terhadap pembelaan yang telah diberikan oleh Pemohon.

Penghakiman diberikan oleh,

-
1. **YAA DATO' HJ. MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

-
2. **YA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

-
3. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor